OBJECTIF
BARREAU

LES ESSENTIELS DU DROIT

-

DROIT INTERNATIONAL PRIVE

1. Le Droit international privé

Lorsque le juge est saisi d'un litige, il doit commencer par déterminer s'il s'agit d'un litige interne ou s'il est en présence d'une situation internationale. De la nature – interne ou internationale – du litige dépendra l'application du droit interne français ou du droit international privé.

En présence d'un litige interne, le juge français applique en principe le droit français. En présence d'un litige international, caractérisé par un élément d'extranéité, il convient de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de déterminer notamment la juridiction compétente et la loi applicable. L'application des règles de droit international privé ne conduit pas nécessairement à l'application d'une loi étrangère : la règle de conflit peut parfaitement désigner la loi française

Pour démontrer l'internationalité du litige, vous devez, en droit international privé, identifier un élément d'extranéité, un élément territorial qui ne se réalise pas sur le territoire français : par exemple la nationalité de l'une des parties, son domicile, le lieu d'exécution du contrat, etc.

En droit du commerce international, l'internationalité s'apprécie généralement grâce à un critère économique. D'un point de vue économique, une situation est dite internationale « lorsqu'elle met en jeu les intérêts du commerce international » (Civ. 19 février 1930, *Mardelé* et 27 janvier 1931, *Dambricourt*). L'opération est ainsi internationale lorsqu'elle implique un mouvement de biens, de fonds ou de services à travers les frontières, lorsque l'opération internationale ne se dénoue pas économiquement dans un seul État. Cette conception économique de l'internationalité est notamment consacrée à l'article 1504 du Code de procédure civile, selon lequel : « Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. »

Le terme « international » désigne en réalité l'objet de cette branche. En d'autres termes, c'est parce que la situation est internationale qu'il convient d'appliquer le droit international privé.

En revanche, les sources du droit international privé ne sont pas nécessairement « internationales » en elles-mêmes, mais ont aussi une origine nationale. De même, les règles de droit international privé applicables dans un ordre juridique ne sont pas nécessairement internationales.

Les règles de droit international privé peuvent être :

- Celles édictées dans l'ordre juridique du for (législateur ou JP).
- Celles édictées dans un instrument international (Convention internationale ou Règlement européen), duquel l'État dont le juge est saisi est partie ou membre.

Le droit international privé comprend traditionnellement quatre grandes matières : 1/ Les conflits de juridictions : détermination de la juridiction internationalement compétente ; 2/ Les conflits de lois : détermination de la loi applicable à une situation internationale ; 2/ La reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères ; 3/ La nationalité et la condition des étrangers, traditionnellement rattachées au droit international privé français.

1. La *lex fori* ou loi du for

L'expression "Lex fori" est d'origine latine, elle signifie "la loi (lex) applicable au lieu où se trouve installé le tribunal (for) devant lequel l'affaire est portée". En français la "loi du for". En droit international privé, il convient de distinguer la loi applicable à la procédure et celle applicable au fond du litige.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La loi applicable à la procédure. En principe, la procédure est régie par la loi du for. Ainsi, lorsqu'un juge français est saisi d'un litige international, il applique les règles françaises de procédure, sous réserve des dispositions européennes ou internationales applicables

La loi applicable au fond. La loi du for n'est pas nécessairement applicable au fond du litige. Le juge doit mettre en œuvre la règle de conflit de lois pertinente, qui peut désigner la loi française ou une loi étrangère. Cette règle de conflit peut notamment résulter d'un règlement européen, d'une convention internationale ou, à défaut, du droit international privé commun français.

Le cas particulier de l'arbitrage international. En matière d'arbitrage international, l'article 1511 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit choisies par les parties ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.

.

2. Les règles de DIP dans le Code civil

On peut citer l'article 3 ainsi que les articles 14 et 15 sur la compétence des juridictions françaises.

L'article 3 est une disposition clef du droit international privé commun. Il dispose que :

« *Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.*

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les français, même résidant en pays étranger ».

Il convient toutefois de vérifier prioritairement l'existence d'un règlement européen ou d'une convention internationale applicable, qui peut écarter le recours aux règles françaises de conflit de lois de droit commun

L'article 14 dispose que « *L'étranger, même non-résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français* ».
L'article 15 énonce qu'« *Un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger* »..

Les articles 14 et 15 du Code civil instituent des privilèges de juridiction fondés sur la nationalité française. L'article 14 permet, sous certaines conditions, à un demandeur français de saisir les juridictions françaises contre un défendeur étranger. L'article 15 permet, sous certaines conditions, d'attraire un défendeur français devant les juridictions françaises. Ces privilèges ont un caractère subsidiaire : ils ne peuvent être invoqués lorsqu'une règle européenne ou internationale applicable régit la compétence et en exclut l'application. Leur portée a par ailleurs été étendue par la jurisprudence au-delà des seules obligations contractuelles expressément visées par les textes.

Le Code civil contient également diverses dispositions spéciales de droit international privé, notamment en matière de filiation, de mariage, de divorce et de nationalité. Le droit international privé français demeure toutefois largement issue de la jurisprudence sous réserve de l'application des instruments européens et internationaux

3. Les sources internationales de DIP

Parmi les sources internationales, les principales sont les traités. Les traités peuvent être bilatéraux (entre deux Etats) ou multilatéraux (entre plusieurs Etats). Un exemple de convention bilatérale est la convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire.

Les traités multilatéraux sont souvent conclus dans un cadre institutionnel comme par exemple :

- La Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI)

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La célèbre convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM) a vu le jour au sein de cette instance.

- La Conférence de La Haye

La Conférence de La Haye de droit international privé, dont la première session remonte à 1893, est une organisation intergouvernementale permanente depuis 1955. Elle œuvre à l'unification progressive des règles de droit international privé, notamment par l'élaboration de conventions internationales. s.

On peut citer, à titre d'exemple, la convention de La Haye du 15 juin 1955, sur la loi applicable à la vente internationale d'objets mobiliers corporels ; la convention de La Haye du 4 mai 1971, sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière ; la convention de La Haye du 2 octobre 1973, sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits.

Il y a beaucoup de Conventions de La Haye dans le domaine du droit de la famille ainsi que de l'état et de la capacité des personnes.Les conventions de La Haye peuvent porter sur les conflits de lois, les conflits de juridictions, la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères, ainsi que sur la coopération judiciaire et administrative internationale. La Convention de 1996, à titre d'exemple, traite expressément de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance, de l'exécution et de la coopération en matière de protection des enfants. .

- Certaines conventions ont également été adoptées entre États membres de l'Union européenne sous l'impulsion de l'ancienne Communauté européenne

On peut citer la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que la convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles : ces deux conventions ont depuis été remplacées par des règlements européens. Vous n'aurez donc à les appliquer que si les faits de votre cas pratique étaient très anciens... ce qui n'est pas extrêmement probable.

- Il faut également évoquer de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 par les membres du Conseil de l'Europe. Ces dispositions peuvent notamment intervenir en matière de reconnaissance des situations familiales constituées à l'étranger, de filiation, de vie familiale ou de reconnaissance des décisions étrangères Si la CEDH n'a pas pour objet de trancher directement une question de droit international privé, elle est susceptible d'influencer de nombreuses solutions de droit international privé.

Il convient de préciser que la Convention européenne des droits de l'homme offre un rayonnement d'évidence sur le droit international privé, notamment à travers l'article 6 relatif au droit à un procès équitable, l'article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et l''article 14, relatif à l'interdiction des discriminations dans la jouissance des droits garantis par la Convention.

En outre,parmi les conventions particulièrement importantes figurent également dans le catalogue officiel de la Conférence de la Haye : 1/ La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; 2/ La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale ; 3/ La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la responsabilité parentale et les mesures de protection des enfants ; 4/ La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

4. Les sources européennes de DIP

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Les anciennes conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Rome du 19 juin 1980 ont été progressivement remplacées, dans leurs domaines respectifs, par des règlements européens. Ces instruments contribuent à l'unification des règles de droit international privé au sein de l'Union européenne, dans leurs champs d'application respectifs. Sans souci d'exhaustivité, on peut citer

- le règlement Bruxelles I bis : le Règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 remplace le Règlement (CE) n°44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
- le règlement Bruxelles II bis : le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
- le règlement Bruxelles II ter : Règlement (UE) du 2 5 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants.
- le règlement Rome I : Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Contrats conclus postérieurement au 17 décembre 2009.
- le règlement Rome II : Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Faits générateurs du dommage survenus à compter du postérieurs au 11 janvier 2009.
- le règlement obligations alimentaires : Règlement no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
- le règlement successions : Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Successions ouvertes à compter du 17 août 2015.
- le règlement sur les régimes matrimoniaux : Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Applicable pour les époux mariés à compter du 29 janvier 2019.
- le règlement relatif aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés : Règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
- Le règlement Rome III : règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable depuis le 21 juin 2012. Conserve également les règlements relatifs aux obligations alimentaires, aux successions, aux régimes matrimoniaux et aux partenariats enregistrés

Attention ! Le règlement Bruxelles II ter est applicable depuis le 1er août 2022. Il a remplacé Bruxelles II bis pour les procédures relevant de son champ d'application et introduites à compter de cette date, sous réserve des dispositions transitoires. Il faut donc connaître Bruxelles II ter sans considérer que Bruxelles II bis a disparu pour toutes les situations anciennes

- Pour rappel, les règlements européens sont d'application directe dans l'ordre juridique interne d'un Etat.

5. Les règles de compétences internationales

Lorsqu'un litige présente un élément d'extranéité, il convient de déterminer quelle juridiction est internationalement compétente pour en connaître. En principe, les litiges privés internationaux sont tranchés par les juridictions étatiques, sous réserve notamment du recours à l'arbitrage international. Le juge français saisi d'un litige international doit déterminer sa propre compétence en appliquant les règles de compétence

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

internationale pertinentes. Il convient de rechercher par priorité l'existence d'un règlement européen ou d'une convention internationale applicable, avant de recourir, le cas échéant, aux règles françaises de droit international privé commun

.

6. Le règlement Bruxelles I bis

L'article 1.1 précise que le règlement Bruxelles I bis porte sur la « matière civile et commerciale » et qu'il ne s'applique « *ni aux matières fiscales, douanières ou administratives ni à la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii)* ». L'idée étant que le droit privé relève des textes de Bruxelles, tandis que les matières de droit public devraient être exclues. Une telle distinction n'est pourtant pas aisée à dessiner.

L'article 1.2 du règlement Bruxelles I bis dresse une liste de matières exclues de son champ d'application.
Sont ainsi exclus :

« a*) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations, qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage ; b) les faillites, concordats et autres procédures analogues ; c) la Sécurité sociale ; d) l'arbitrage ; e) les obligations alimentaires découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance ; f) les testaments et successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès* ».

Le principe de compétence du domicile du défendeur. L'article 4 du règlement Bruxelles I bis prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont, en principe, attraites devant les juridictions de cet État membre, quelle que soit leur nationalité. Ce principe connaît plusieurs exceptions qui peuvent être énumérées de la manière suivante : 1/ Les compétences spéciales de l'article 7, en particulier en matière contractuelle et délictuelle ; 2/ Les compétences protectrices en matière d'assurance, de contrats de consommation et de contrats individuels de travail ; 3/ Les compétences exclusives prévues à l'article 24 ; 4/Les clauses attributives de juridiction régies par l'article 25. Lorsque le défendeur n'est pas domicilié dans un État membre, la compétence est en principe déterminée par le droit national du juge saisi, sous réserve notamment des articles 24 et 25 et des dispositions protectrices applicables

7. Le règlement Bruxelles II Ter

Le règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, est applicable depuis le 1er août 2022. Il remplace le règlement Bruxelles II bis, sous réserve des dispositions transitoires. Il concerne la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi que l'enlèvement international d'enfants. Il comporte deux volets principaux :

1. **La matière matrimoniale**. Le règlement s'applique au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage. Il ne détermine pas la loi applicable au divorce, question relevant notamment du règlement Rome III.

2. **La responsabilité parentale**. Le règlement s'applique notamment aux questions relatives au droit de garde, au droit de visite, à la tutelle, à la curatelle, au placement de l'enfant et à certaines mesures de protection de ses biens. La notion de responsabilité parentale est entendue largement : elle vise les droits et obligations concernant la personne ou les biens d'un enfant. Le règlement contient également des dispositions relatives à l'enlèvement international d'enfants et à la coopération entre autorités des États membres.

8. Le règlement relatif aux obligations alimentaires

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Applicable en France à compter du 18 juin 2011, le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires confirme l'européanisation du droit international privé de la famille. Il comporte des règles relatives à la compétence juridictionnelle, à la loi applicable et à la reconnaissance et l'exécution des décisions. S'agissant de la loi applicable, l'article 15 du règlement renvoie au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, pour les États membres liés par cet instrument. En principe, selon l'article 3 de ce Protocole, les obligations alimentaires sont régies par la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier d'aliments, sous réserve des règles spéciales et des exceptions prévues par le texte

9. Le règlement sur les successions

Le règlement n° 650/2012/UE du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, « règlement Successions », a transformé complètement le droit international privé des successions dans les États membres de l'Union européenne, en particulier celui de la France. Le règlement Successions consacre en principe l'unité de la succession en abandonnant la distinction traditionnelle entre successions mobilières et immobilières. Il retient principalement le critère de la résidence habituelle du défunt au moment du décès tant pour la compétence juridictionnelle que pour la loi applicable, sous réserve des exceptions prévues par le règlement. Le défunt peut notamment choisir, dans les conditions prévues à l'article 22, la loi de l'État dont il possède la nationalité pour régir l'ensemble de sa succession

.

A retenir : résidence habituelle du défunt = critère de principe ; choix de la loi nationale = possibilité de professio juris

10. Le règlement sur les régimes matrimoniaux

Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, couvre à la fois la compétence juridictionnelle, la loi applicable, la reconnaissance, la force exécutoire et l'exécution des décisions ainsi que les actes authentiques et les transactions judiciaires.

Le règlement (UE) 2016/1103 vise à unifier les règles de droit international privé relatives aux régimes matrimoniaux dans les États membres participant à la coopération renforcée. Applicable depuis le 29 janvier 2019, il prévoit des dispositions transitoires. Son chapitre relatif à la loi applicable concerne les époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial à compter du 29 janvier 2019. Le règlement favorise la prévisibilité notamment pour les couples internationaux dont les résidences habituelles ou les biens sont situés dans différents États

.

11. Le droit commun de la compétence internationale

Lorsqu'on a établi qu'aucun instrument européen ou qu'aucune convention ne s'appliquait, c'est-à-dire après avoir vérifié l'applicabilité matérielle, spatiale et temporelle des règlements susceptibles de s'appliquer, alors on peut s'en remettre aux règles du droit commun français de la compétence internationale: les règles de compétence juridictionnelle d'origine nationale sont subsidiaires. Elles sont propres à chaque ordre juridique et ne sont mises en œuvre QUE devant le juge de l'ordre juridique qui les a édictées.

La compétence internationale de droit commun. En l'absence de règlement européen ou de convention internationale applicable, le juge français détermine sa compétence conformément aux règles françaises de droit international privé commun. Ces règles sont principalement issues de l'extension à l'ordre international des

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

règles françaises de compétence territoriale interne, sous réserve des adaptations nécessaires. Il convient de distinguer entre 1/ la compétence internationale directe, qui permet au juge français de déterminer s'il est compétent pour connaître du litige et 2/ La compétence internationale indirecte, qui permet notamment de contrôler la compétence du juge étranger lorsqu'est demandée en France la reconnaissance d'une décision étrangère. En droit commun, les articles 14 et 15 du Code civil peuvent également fonder la compétence internationale des juridictions françaises, dans les conditions prévues par la jurisprudence.

Focus. Civile 1è 6 février 1985 Simitch n°83-11.241 relatif la compétence indirecte du juge étranger (=/= la détermination ordinaire de la compétence directe du juge français). En matière de compétence internationale indirecte, la Cour de cassation considère que le tribunal étranger doit être reconnu compétent lorsque : 1/ le litige se rattache de manière caractérisée à l'État du juge saisi ; 2/ le choix de la juridiction étrangère n'est pas frauduleux et 3/ aucune règle française de compétence internationale exclusive ne s'y oppose.

.

12. La litispendance

- Définition de la litispendance :La litispendance internationale désigne la situation dans laquelle deux juridictions relevant d'États différents sont saisies de demandes présentant une identité de parties, d'objet et de cause. Elle vise notamment à éviter la multiplication des procédures parallèles et le risque de décisions inconciliables
- .
- Solution en droit international privé commun : par extension de l'article 100 CPC, la Cour de cassation a jugé dans l'arrêt Soc. Miniera di Fragne, que l'exception de litispendance était recevable devant le juge français à la condition que la décision étrangère soit susceptible d'être reconnue sur le territoire français (Civ. 1er, 26 novembre 1974, Société Miniera di Fragne).
- Quelles sont les conditions visées dans l'arrêt Société Miniera di Fragne ? L'arrêt du 26 novembre 1974 subordonne expressément l'accueil de l'exception à la possibilité de reconnaître en France la décision étrangère à intervenir. Dans ces circonstances, la Cour de cassation a admis la possibilité d'accueillir une exception de litispendance internationale. Cette exception suppose notamment : 1/ l'existence de procédures parallèles présentant une identité de parties, d'objet et de cause ; 2/ la saisine antérieure de la juridiction étrangère ; 3/ la compétence internationale indirecte du juge étranger ; 4/ la possibilité de reconnaître en France la décision étrangère à intervenir. Le juge français doit ainsi apprécier par anticipation si la décision étrangère pourra être reconnue en France. En droit commun, le dessaisissement du juge français second saisi n'est pas automatique
- .
- L'accueil de l'exception de litispendance est ainsi subordonné à un pronostic de reconnaissance de la décision étrangère à venir. La mise en œuvre de l'exception de litispendance internationale en droit français implique alors, pour le juge, de vérifier de manière anticipée et fictive les conditions de la régularité des jugements étrangers, ce qui est nécessairement aléatoire.
- **La litispendance dans le règlement Bruxelles I bis.** On doit ici distinguer la litispendance entre États membres de celle engageant un État tiers.
    - L'article 29 du règlement Bruxelles I bis prévoit que, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. Lorsque cette compétence est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit au profit de la première. Ce mécanisme connaît notamment une exception à l'article 31 paragraphe 2 lorsqu'une juridiction désignée par une clause attributive de juridiction exclusive est saisie dans les conditions prévues par le règlement.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Les Etats tiers. Les articles 33 et 34 du règlement Bruxelles I bis prévoient également, sous certaines conditions, des mécanismes de suspension de l'instance lorsqu'une procédure est déjà pendante devant une juridiction d'un État tiers

13. La connexité

Il convient ici de transposer l'article 101 du CPC qui définit la connexité comme la situation dans laquelle « *il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble* ».

Quelles sont les conditions de la connexité ? La Cour de cassation a précisé les conditions d'application de l'exception de connexité internationale. Elle a jugé que « *l'exception de connexité internationale peut être admise aux seules conditions que deux juridictions relevant de deux États différents soient également et compétemment saisies de deux instances, en cours, faisant ressortir entre elles un lien de nature à créer une contrariété* ». (Civile 1è 22 juin 1999 n° 96-22.546) .La connexité internationale suppose que deux juridictions relevant d'États différents soient également et compétemment saisies de deux instances en cours, présentant entre elles un lien de nature à créer un risque de contrariété de décisions. Le juge français dispose d'une faculté de dessaisissement au profit de la juridiction étrangère également compétente. La connexité se distingue de la litispendance en ce qu'elle ne suppose pas une identité des demandes mais bien un lien suffisamment étroit entre elles.

La connexité dans le règlement Bruxelles I bis. L'article 30 du règlement Bruxelles I bis prévoit que, lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Elle peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, lorsque l'affaire devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, que cette juridiction est compétente pour connaître des demandes et que sa loi permet leur jonction. Contrairement à la litispendance prévue à l'article 29, le sursis à statuer en matière de connexité est facultatif.

.

14. Les clauses attributives de juridiction

Le principe est donc celui de la licéité de la clause attributive de juridiction dans l'ordre international.

En droit interne français, la clause est réputée non- écrite sauf dans les relations entre commerçants et à condition d'être spécifiée de manière très apparente (art. 48 CPC):

« *Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée* ».

Alors que la question s'était longtemps posée de savoir si la prohibition de l'article 48 devait être étendue à l'ordre international, la Cour de cassation a finalement reconnu que les clauses attributives de juridiction sont valables dans l'ordre international à la condition toutefois que le litige soit réellement international et qu'elles ne fassent pas échec à une compétence impérative (Cass. Civ. 1er, 17 déc. 1985, Cie de signaux et d'entreprises électriques).

Une clause attributive de juridiction et une clause de choix de loi ne sont pas la même chose. La première désigne le juge compétent ; la seconde désigne le droit applicable au fond

15. Qu'est-ce que l'Exequatur ?

De manière générale, un jugement a été rendu à l'étranger et il est question de lui faire produire des effets sur le territoire d'un autre État, notamment sur le territoire français. À titre d'exemple, le créancier souhaite saisir les biens de son débiteur sur le territoire français. Le demandeur peut également rechercher devant le juge

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

français l'autorité de chose jugée du jugement étranger. Le but étant d'éviter qu'un nouveau procès ne soit diligenté en France.

L'exequatur est une procédure visant à donner, dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger ou à une sentence arbitrale. Cette dernière précision est importante : l'exequatur n'est plus systématiquement nécessaire au sein de l'Union européenne. En effet, un jugement rendu dans un État n'est pas forcément reconnu dans un autre État. Quand bien même un jugement serait reconnu dans un autre État que celui où il a été prononcé, cette reconnaissance n'implique pas qu'il ait une force exécutoire. li s'agit des conditions énoncées par la Cour de cassation dans l'arrêt Cornelissen (Civile 1è 20 février 2007 n°05-14.082).

16. Les règles de conflit de lois ?

Afin de désigner la loi applicable à la situation internationale, deux méthodes existent concurremment : la méthode « bilatéraliste » et la méthode « unilatéraliste ».

- Règle de conflit bilatérale : on parle de règle de conflit bilatérale pour exprimer l'idée que la règle de détermination de la loi applicable ne désigne pas systématiquement le droit du for - c'est-à-dire le droit du juge saisi - mais peut également désigner une loi étrangère.

Par exemple, l'article 311-14 du Code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et, si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. Cette règle de conflit est bilatérale puisqu'elle peut aussi bien désigner la loi française, lorsque la mère est de nationalité française, qu'une loi étrangère, lorsque celle-ci possède une nationalité étrangère.

- Règle de conflit unilatérale : Au contraire, la règle de conflit unilatérale se contente de fixer le champ d'application de la loi du for, sans permettre la désignation de la loi étrangère.

À titre d'exemple, l'article 309 al. 1er du Code civil énonce que : « le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ». Cette règle se contente de délimiter la compétence de la loi française sans permettre la désignation de la loi étrangère.

Attention : l'article 309 du Code civil a aujourd'hui un champ d'application résiduel depuis l'entrée en application du règlement Rome III (règlement UE n° 1259/2010 du 20 décembre 2010), le 21 juin 2012. Ce règlement détermine la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participant à la coopération renforcée, dont la France. Il présente un caractère universel : la loi désignée s'applique même lorsqu'il s'agit de celle d'un État non-membre de l'Union européenne (article 4). L'article 309 conserve ainsi principalement un intérêt théorique comme illustration de la méthode unilatéraliste, ainsi qu'un domaine d'application résiduel pour les situations ne relevant pas du règlement Rome III

17. Définition des lois de police

Les lois de police présentent la particularité de s'appliquer directement à une situation internationale, indépendamment de la loi normalement désignée par la règle de conflit de lois. Pour cette raison, on considère traditionnellement que la méthode des lois de police est une méthode concurrente de la méthode bilatérale classique. Elle repose sur une logique unilatéraliste, chaque loi de police déterminant son propre champ d'application. Les lois de police du for s'appliquent impérativement aux situations entrant dans leur champ d'application. Certaines lois de police étrangères peuvent également être prises en considération dans les conditions prévues par les instruments applicables.

L'article 9 du règlement Rome I (règlement CE n° 593/2008) définit les lois de police comme des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics, notamment politiques, sociaux ou économiques. L'article 9, paragraphe 2, préserve l'application des lois de police du juge saisi. L'article 9, paragraphe 3, permet également, sous certaines conditions, de donner effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations contractuelles doivent être ou ont été exécutées, lorsque ces dispositions rendent l'exécution du contrat illégale

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

.

18. L’éviction de la loi étrangère

La loi étrangère désignée par la règle de conflit peut être évincée pour deux raisons principales : sa contrariété à l'ordre public international du for et la fraude à la loi. L'exception d'ordre public international permet au juge français d'écarter la loi étrangère normalement applicable lorsque son application concrète conduirait à un résultat manifestement incompatible avec les principes essentiels de l'ordre juridique français. La fraude à la loi consiste à manipuler volontairement un élément de rattachement afin d'échapper à la loi normalement applicable et d'obtenir l'application d'une autre loi. La fraude à la loi a notamment été consacrée par l'arrêt Princesse de Bauffremont (Chambre civile 18 mars 1878). Dans cette affaire, un changement de nationalité avait été utilisé afin de contourner la loi française alors applicable en matière matrimoniale. La Cour de cassation a refusé que cette manœuvre frauduleuse produise les effets recherchés en France

19. L’ordre public interne

L’ordre public interne englobe toutes les dispositions qui revêtent un caractère impératif en ce sens qu’elles s’imposent aux parties sans qu’elles puissent y déroger par accord. Il fait écho à la distinction traditionnelle entre dispositions impératives et dispositions supplétives. L'ordre public international français doit être distingué de l'ordre public interne. Il est plus restreint : toutes les règles impératives du droit français ne constituent pas nécessairement des exigences d'ordre public international. L'ordre public international regroupe les principes essentiels de l'ordre juridique français dont la méconnaissance peut justifier l'éviction d'une loi étrangère normalement applicable. Son intervention s'apprécie notamment au regard du résultat concret auquel conduirait l'application de la loi étrangère

20. L’ordre public international

L'ordre public international n'a pas les mêmes contours que l'ordre public interne, puisqu'une disposition d'ordre public interne ne relève pas nécessairement de l'ordre public international. En droit international privé, l'exception d'ordre public international permet au juge français d'écarter l'application d'une loi étrangère normalement désignée par la règle de conflit lorsque son application concrète conduirait à un résultat manifestement incompatible avec les principes essentiels de l'ordre juridique français. L'appréciation de cette contrariété s'effectue au regard du résultat concret de l'application de la loi étrangère, et non de la seule différence entre cette loi et le droit français . A ce titre, l'article 26 du règlement Rome II consacre expressément l'exception d'ordre public international en prévoyant que l'application d'une disposition de la loi désignée par le règlement ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public du for

1. Le règlement Rome II

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 11 juillet 2007, le règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « règlement Rome II ». Ce texte est essentiel car il a une portée générale. Néanmoins, certaines questions importantes ont été exclues de son champ d’application, si bien que les règles de conflit jurisprudentielles continuent de s’appliquer pour toutes ces questions. Le règlement Rome II s'applique aux faits générateurs de dommages survenus à compter du 11 janvier 2009. Il présente un caractère universel : la loi désignée par le règlement s'applique même lorsqu'il s'agit de celle d'un État non membre de l'Union européenne (article 3). Certaines matières sont exclues de son champ d'application, notamment les obligations non contractuelles découlant des relations de famille, les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, ainsi que les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés, dans les conditions prévues à l'article 1er. Pour les matières exclues, il convient de rechercher les autres instruments éventuellement applicables puis, à défaut, les règles françaises de droit international privé commun

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Le règlement Rome II vise à renforcer la prévisibilité des solutions et la sécurité juridique en privilégiant des critères de rattachement objectifs. L'article 4 paragraphe 1 retient en principe la loi du pays où le dommage survient (lex loci damni), indépendamment du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit et des pays dans lesquels se manifestent les conséquences indirectes de ce fait. Ce rattachement connaît toutefois des tempéraments : l'application de la loi de la résidence habituelle commune des parties (article 4, paragraphe 2), la clause d'exception en faveur de la loi d'un pays présentant des liens manifestement plus étroits avec le fait dommageable (article 4 paragraphe 3), ainsi que la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable dans les conditions prévues à l'article 14 (electio juris)

.

Au sein d'un chapitre II intitulé « faits dommageables », on trouve une règle de conflit générale (article 4). Elle s'applique à défaut de choix de loi applicable (art. 14) et lorsqu'il n'existe pas de règle de conflit plus spéciale en la matière. Le règlement Rome II prévoit également plusieurs règles spéciales de conflit de lois, notamment en matière de responsabilité du fait des produits (article 5), de concurrence déloyale et de restrictions à la libre concurrence (article 6), de dommages environnementaux (article 7) et d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle (article 8). Ces règles spéciales doivent être recherchées avant de recourir à la règle générale de l'article 4

21. Le droit de la nationalité

Chaque État est en principe compétent pour déterminer, par sa législation, les conditions d'attribution, d'acquisition et de perte de sa nationalité, sous réserve du respect de ses engagements internationaux. Ce principe est notamment affirmé par l'article 1er de la Convention de La Haye du 12 avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité. La Cour internationale de justice a également rappelé, dans l'arrêt Nottebohm du 6 avril 1955, qu'il appartient en principe à chaque État de déterminer les conditions d'attribution de sa nationalité. Elle a toutefois distingué l'attribution de la nationalité de son opposabilité aux autres États dans le cadre de la protection diplomatique. Les règles de nationalité étant principalement nationales, plusieurs États peuvent attribuer leur nationalité à un même individu, entraînant une situation de pluralité de nationalités. À l'inverse, une personne peut se trouver en situation d'apatridie lorsqu'aucun État ne la considère comme son ressortissant par application de sa législation

.

22. La nationalité française

Un individu peut se voir reconnaître la nationalité française à la naissance – c'est l'attribution de la nationalité – l'obtenir par la suite – c'est l'acquisition de la nationalité – ou encore la perdre.

23. Le droit du sang

Concernant le droit du sang, l'article 18 du Code civil dispose qu' : « *Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français* ».

Dès lors que le père ou la mère est français, la nationalité française est transmise à l'enfant. Lorsque seul l'un des parents est français et que l'enfant est né à l'étranger, celui-ci dispose de la faculté de répudier la nationalité française dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois suivant celle-ci (article 18-1 du Code civil). Cette faculté disparaît si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. La répudiation suppose toutefois que l'intéressé prouve qu'il possède, par filiation, la nationalité d'un État étranger (article 20-3 du Code civil)

.

2. Le droit du sol

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

La seule naissance en France ne suffit pas, en principe, à attribuer la nationalité française à un enfant né de parents étrangers. Le Code civil prévoit toutefois plusieurs hypothèses d'attribution de la nationalité française dès la naissance. L'article 19 du Code civil prévoit qu'est français l'enfant né en France de parents inconnus. Toutefois, il est réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il possède la nationalité de celui-ci conformément à sa loi nationale. L'article 19-1 du Code civil attribue également la nationalité française à l'enfant né en France de parents apatrides ou de parents étrangers dont les lois nationales ne permettent en aucune façon la transmission de leur nationalité à l'enfant. Toutefois, l'enfant est réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise

.

La naissance en France peut permettre d'attribuer la nationalité française lorsque l'un des parents de l'enfant est également né en France (article 19-3 du Code civil). Si un seul des deux parents est né en France, l'enfant peut répudier la nationalité française dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans l'année qui suit (article 19-4). Cette faculté disparaît lorsque l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.

Que la nationalité française soit attribuée à l'enfant par le droit du sol ou du sang, il est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions d'attribution de la nationalité n'est prouvée qu'ultérieurement (art. 20).

Au titre de l'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France, l'article 21-7 du Code civil prévoit que l'enfant né en France de parents étrangers acquiert de plein droit la nationalité française à sa majorité s'il réside en France à cette date et s'il y a eu sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans. L'article 21-11 permet également une acquisition anticipée par déclaration : 1/ À partir de seize ans, à l'initiative du mineur, sous réserve des conditions de résidence prévues par le texte ; 2/ À partir de treize ans, au nom du mineur, avec son consentement, sous réserve notamment d'une résidence habituelle en France pendant au moins cinq ans depuis l'âge de huit ans. Il convient ainsi de distinguer l'attribution de la nationalité française dès la naissance, notamment par le double droit du sol, de son acquisition ultérieure en raison de la naissance et de la résidence en France.

Enfin, il convient d'évoquer la réforme du droit du sol à Mayotte. La loi n° 2025-412 du 12 mai 2025 visant à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte a modifié l'article 2493 du Code civil. Depuis le 14 mai 2025, l'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence à Mayotte, dans les conditions des articles 21-7 et 21-11 du Code civil, est subordonnée à une condition supplémentaire. À la date de naissance de l'enfant, ses deux parents doivent résider en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an. Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ces conditions s'appliquent uniquement à ce parent. A noter que cette réforme concerne les mécanismes d'acquisition de la nationalité prévus aux articles 21-7 et 21-11 et qu'elle ne doit pas être confondue avec les règles générales d'attribution de la nationalité française dès la naissance.

24. L'apatridie

Une personne est apatride lorsqu'aucun État ne la considère comme sa ressortissante par application de sa législation. En l'absence de nationalité, la détermination de la loi applicable au statut personnel de l'apatride nécessite un critère de rattachement différent de la nationalité. L'article 12 de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides prévoit que le statut personnel de l'apatride est régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. La Convention prévoit également la protection des droits précédemment acquis par l'apatride et dépendant de son statut personnel, notamment les droits résultant du mariage, dans les conditions prévues par son article 12

.

25. L'entrée en France des étrangers : les conditions d'admission sur le territoire français

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'article L. 311-1 du CESEDA précise les documents qui doivent être fournis pour l'entrée sur le territoire français. Il s'agit :

- Des documents et visas exigés par les conventions internationales et règlements en vigueur. L'exigence d'un visa est supprimée pour certains ressortissants comme pour les ressortissants d'États membres de l'Union européenne par exemple.
- Sous réserve des conventions internationales et des cas de dispense, d'un justificatif d'hébergement lorsqu'il est requis. Pour une visite familiale ou privée d'une durée n'excédant pas trois mois, ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par l'hébergeant et validée par le maire compétent (art. L. 313-1 et L. 313-2 du CESEDA). L'hébergeant s'engage, si l'étranger ne peut y pourvoir, à prendre en charge ses frais de séjour dans les limites et pour la durée prévues à l'article L. 313-2. .
- Des documents relatifs à l'objet et aux conditions de séjour.
- Des documents relatifs aux moyens d'existence et à la prise en charge des dépenses médicales et hospitalières par un opérateur d'assurance agréé. Il s'agit de justifier de ressources suffisantes pour le séjour et de la couverture des dépenses de soins susceptibles d'être engagées en France, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du CESEDA. .
- Des documents relatifs aux garanties de rapatriement
- Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle si l'étranger se propose d'en exercer une.

26. Le séjour en France

Un étranger admis pour un court séjour peut, sous réserve de respecter les conditions de son entrée et de son séjour, demeurer dans l'espace Schengen pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Il ne dispose donc pas, du seul fait de son entrée en France, d'un droit inconditionnel de séjourner pendant trois mois. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des régimes particuliers, l'article L. 411-1 du CESEDA prévoit que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans souhaitant séjourner en France plus de trois mois doit être titulaire d'un document l'y autorisant. Depuis sa modification par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, cet article énumère notamment les documents suivants :

1. Un visa de long séjour ;
2. Un visa de long séjour conférant les droits attachés à certains titres de séjour ;
3. Une carte de séjour temporaire ;
4. Une carte de séjour pluriannuelle ;
5. Une carte de résident ;
6. Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ;
7. Une carte de séjour portant la mention "retraité" ;
8. Certaines autorisations provisoires de séjour prévues par le CESEDA.

Les ressortissants de l'Union européenne et les membres de leur famille relèvent de règles particulières relatives à la libre circulation et au séjour. Il faut donc éviter de leur appliquer indistinctement le régime général de l'article L. 411-1 CESEDA.

-

27. Le regroupement familial

Le Conseil d'État a consacré le droit des étrangers résidant régulièrement en France de mener une vie familiale normale, qui comporte notamment la faculté de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs (CE Ass. 8 décembre 1978, GISTI, CFDT et CGT). Ce droit trouve son fondement dans les principes généraux du droit et notamment dans le Préambule de la Constitution de 1946. Il peut faire l'objet de conditions destinées à le concilier avec les exigences d'ordre public et de protection sociale. Ce droit découle également de l'article 8 de la CEDH qui garantit notamment le droit au respect de la vie privée et familiale. Les articles L. 434-2 à L. 434-12 du CESEDA fixent les modalités du regroupement familial

.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

.

En vertu de l'article L. 434-2 du CESEDA, l'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le CESEDA ou par une convention internationale, peut demander à être rejoint par son conjoint âgé d'au moins dix-huit ans et par les enfants mineurs du couple. Certains membres de la famille peuvent être exclus du regroupement familial notamment si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, s'ils sont atteints d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou s'ils résident déjà en France (art. L. 434-6 du CESEDA). Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Les enfants de cet autre conjoint en sont également exclus, sauf si ce dernier est décédé ou déchu de ses droits parentaux (art. L. 434-9 du CESEDA). .

L'article L. 434-7 du CESEDA subordonne le regroupement familial à trois conditions principales : le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; disposer, ou pouvoir disposer à l'arrivée de celle-ci, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; et se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France conformément aux lois de la République. L'article L. 434-8 précise les modalités d'appréciation des ressources et prévoit certaines exceptions à cette condition. Ces exigences s'articulent avec les exclusions prévues à l'article L. 434-6 et les dispositions particulières relatives à la polygamie prévues à l'article L. 434-9

28. Le droit du commerce international

Le droit du commerce international désigne les règles applicables aux échanges économiques internationaux. Ce droit revêt aujourd'hui une importance particulière, la mondialisation ayant entraîné une démultiplication de ces échanges.

Les personnes privées ne sont pas les seules à prendre part au commerce international, les États y participent également activement. L'État intervient dans le commerce international en tant que régulateur mais aussi en tant qu'opérateur du commerce international. Il adopte ainsi les règles applicables aux échanges internationaux mais participe aussi à ces échanges notamment en concluant des contrats avec des personnes privées.

Les sources du droit du commerce international sont nombreuses, tant au niveau français, européen qu'international. Certaines institutions internationales sont spécialisées comme l'Organisation Mondiale du Commerce. La politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l'Union européenne (article 3, paragraphe 1, e), et article 207 du TFUE). L'Union peut ainsi négocier et conclure des accords commerciaux internationaux dans le champ de cette compétence. Il ne faut toutefois pas en déduire que l'ensemble du droit du commerce international relève de sa compétence exclusive : les contrats commerciaux internationaux demeurent également régis par des règles nationales, européennes et conventionnelles. .

3. L'immunité de juridiction des Etats

L'immunité de juridiction permet à un État d'échapper, dans certaines conditions, à la compétence des juridictions d'un autre État. Elle repose sur le principe d'égalité souveraine des États. Cette immunité n'est toutefois pas absolue. Il convient de distinguer les actes accomplis dans l'exercice de la souveraineté étatique (actes jure imperii), susceptibles de bénéficier de l'immunité, des actes de gestion ou de commerce (actes jure gestionis), pour lesquels l'immunité peut être écartée. L'immunité de juridiction doit également être conciliée avec le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La reconnaissance d'une immunité conforme aux règles pertinentes du droit international n'est pas, par elle-même, incompatible avec cette disposition.

Il faut distinguer l'immunité de juridiction de l'immunité d'exécution. La première fait obstacle, lorsqu'elle

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

s'applique, à ce qu'un État soit jugé par une juridiction étrangère ; la seconde protège, sous des conditions distinctes, certains biens étatiques contre les mesures d'exécution forcée

.

29. La vente internationale de marchandises

La France est partie à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises (CVIM). Cette convention a connu un grand succès et a été ratifiée par de nombreux États dont la France.

Il s'agit d'une convention ayant unifié les règles substantielles applicables aux contrats internationaux de vente de marchandises. Elle pose donc des règles matérielles et non des règles de conflit de lois. La CVIM ne s'applique pas à toute vente comportant un élément d'extranéité. En vertu de son article 1er, elle concerne les contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque ces États sont contractants ou lorsque les règles de droit international privé conduisent à l'application de la loi d'un État contractant, sous réserve des déclarations et exclusions applicables. Les parties peuvent exclure l'application de la Convention ou déroger à certaines de ses dispositions, conformément à son article 6. La Convention ne régit pas toutes les questions relatives au contrat : elle laisse notamment hors de son champ, en principe, la validité du contrat et les effets de celui-ci sur la propriété des marchandises

La CVIM s'applique matériellement aux contrats de vente de marchandises relevant de son champ d'application, sous réserve des exclusions prévues par la Convention. L'article 3 précise son application à certains contrats mixtes :

1. Les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire sont assimilés à des ventes, sauf si la partie qui commande les marchandises fournit une part essentielle des éléments matériels nécessaires à leur fabrication ou à leur production.
2. La Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'œuvre ou d'autres services.

On voit donc que la CVIM peut s'appliquer à une vente de marchandises à fabriquer ou à produire mais elle est écartée lorsque le contrat porte principalement sur une prestation de services

.

4. Qu'est-ce qu'un traité bilatéral d'investissements (TBI) ?

Le droit international de l'investissement constitue une garantie essentielle pour l'investisseur par rapport au droit interne. Si le droit interne de l'État d'accueil peut offrir de nombreuses garanties à l'investisseur, il peut également être modifié ultérieurement par cet État et ces garanties peuvent disparaître.

À la différence de sa législation interne, un État ne peut pas modifier unilatéralement les obligations internationales qu'il a acceptées dans un traité d'investissement. Le droit international de l'investissement repose notamment sur les traités, la coutume internationale et les principes généraux du droit, selon les questions en cause. .

Depuis la fin du XXe, les traités de protection de l'investissement, principalement bilatéraux, ont connu un essor considérable. Les traités bilatéraux de protection de l'investissement (TBI) constituent aujourd'hui la source principale du droit de l'investissement.

Les TBI ne contiennent pas, bien entendu, tous, les mêmes dispositions. Certaines d'entre elles se retrouvent toutefois de manière quasiment systématique dans ces traités.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Différents standards de protection figurent classiquement dans les TBI : le traitement national, le traitement juste et équitable, le traitement de la nation la plus favorisée, ainsi que la protection contre l'expropriation directe ou indirecte, généralement encadrée par des conditions d'intérêt public, de non-discrimination et d'indemnisation. De nombreux TBI prévoient également un mécanisme de règlement des différends entre l'investisseur et l'État d'accueil, notamment par voie d'arbitrage international. Dans l'arrêt Achmea du 6 mars 2018 (CJUE C-284/16), la Cour de justice a jugé incompatible avec le droit de l'Union la clause d'arbitrage entre investisseur et État contenue dans le TBI en cause, conclu entre deux États membres. À la suite de cet arrêt, un accord plurilatéral signé le 5 mai 2020 a organisé l'extinction des TBI conclus entre les États membres qui y sont parties. Il faut donc distinguer les TBI conclus entre États membres de l'Union européenne des traités d'investissement conclus avec des États tiers.

.

30. Le traitement national

Le traitement national oblige l'État d'accueil, dans les conditions prévues par le TBI applicable, à ne pas accorder aux investisseurs de l'autre État contractant un traitement moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs placés dans des circonstances comparables. Pour déterminer si ce standard a été méconnu, il convient d'abord de vérifier si l'investisseur étranger et l'investisseur national se trouvent dans des situations comparables, notamment au regard de leur activité et du contexte de l'investissement. Il faut ensuite rechercher si l'investisseur étranger a subi un traitement moins favorable. Une différence de traitement ne constitue toutefois pas nécessairement une violation du traité : il faut tenir compte de la rédaction de la clause, de son champ d'application et des éventuelles exceptions ou justifications admises par le TBI

.

5. Le traitement juste et équitable

Dans la plupart des TBI, chaque État contractant s'engage à assurer un traitement juste et équitable aux investisseurs de l'autre État. Le concept est toutefois flou et il est délicat de déterminer, avec précision, le comportement que l'État doit adopter pour être juste et équitable. Les manquements à ce standard caractérisés, par les tribunaux arbitraux, sont variés.

Illustrations. Le traitement juste et équitable peut notamment être invoqué en présence d'un déni de justice, d'une procédure manifestement inéquitable, d'un comportement arbitraire ou d'un manque grave de transparence de l'État d'accueil, selon les termes du traité applicable. Ce standard peut également protéger les attentes légitimes de l'investisseur. Il ne garantit toutefois pas l'immuabilité de la législation de l'État d'accueil : toute modification de la réglementation ne constitue pas, à elle seule, une violation du traitement juste et équitable. L'appréciation dépend notamment des engagements précis éventuellement pris par l'État, du contexte dans lequel l'investissement a été réalisé et du caractère raisonnable des attentes invoquées. Enfin, la seule inexécution d'un contrat par l'État ne suffit pas nécessairement à caractériser une violation du TBI. Il faut distinguer la responsabilité contractuelle de l'État de sa responsabilité internationale au titre du traité

6. La clause de la nation la plus favorisée

La clause de la nation la plus favorisée oblige l'État d'accueil, dans les conditions prévues par le TBI, à accorder aux investisseurs de l'autre État contractant un traitement au moins aussi favorable que celui qu'il réserve aux investisseurs d'un État tiers. Elle peut ainsi permettre à un investisseur de bénéficier d'un traitement plus favorable accordé par l'État d'accueil dans un autre traité, que celui-ci soit antérieur ou postérieur au TBI applicable. Sa portée dépend toutefois de sa rédaction et des éventuelles exclusions prévues par le traité. Par exemple, si un TBI conclu entre la France et l'État A contient une clause de la nation la plus favorisée et que la France accorde aux investisseurs de l'État B une protection plus favorable, un investisseur de l'État A pourra chercher à invoquer cette protection dans les limites de la clause applicable. L'application de la clause aux

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

mécanismes de règlement des différends, notamment à l'arbitrage, ne doit pas être présumée : elle dépend de l'interprétation du traité concerné.

7. La protection contre la nationalisation

La plupart des TBI encadrent les mesures d'expropriation ou de nationalisation prises par l'État d'accueil. Ils protègent généralement les investisseurs contre les expropriations directes, qui entraînent un transfert de propriété, mais également contre certaines expropriations indirectes, lorsque des mesures étatiques privent substantiellement l'investisseur de la valeur ou de l'usage de son investissement sans transfert formel de propriété. Les TBI subordonnent généralement la licéité de l'expropriation à plusieurs conditions : la poursuite d'un objectif d'utilité publique, l'absence de discrimination, le respect de la procédure applicable et le versement d'une indemnisation conforme aux exigences du traité. Les modalités d'évaluation et de versement de cette indemnisation varient selon les TBI

.

8. Le recours à l'arbitrage

De nombreux TBI prévoient une offre d'arbitrage par laquelle l'État d'accueil consent par avance, dans les limites fixées par le traité, à soumettre certains différends l'opposant à un investisseur étranger à un tribunal arbitral. Le consentement des parties peut ainsi être exprimé à des moments différents : l'État formule son offre dans le TBI et l'investisseur l'accepte ultérieurement en engageant une procédure d'arbitrage conformément aux conditions prévues par le traité. On parle de consentement dissocié. L'existence d'un TBI ne suffit toutefois pas à établir la compétence du tribunal arbitral. Il faut vérifier notamment que le différend entre dans le champ de la clause d'arbitrage, que l'investisseur et l'investissement bénéficient de la protection du traité et que les éventuelles conditions préalables à la saisine ont été respectées

.

31. L'arbitrage

L'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des différends par lequel les parties confient à un ou plusieurs arbitres le pouvoir de trancher leur litige en rendant une sentence arbitrale. Il se distingue de la médiation et de la conciliation : le médiateur ou le conciliateur aide les parties à rechercher un accord, tandis que l'arbitre tranche le différend par une décision qui s'impose aux parties, sous réserve des voies de recours et des règles relatives à sa reconnaissance et à son exécution. L'arbitrage repose en principe sur le consentement des parties, exprimé dans une convention d'arbitrage. En droit français, l'arbitrage est international lorsqu'il met en cause des intérêts du commerce international (article 1504 du Code de procédure civile)

.

32. Arbitrage *Ad hoc* et arbitrage institutionnel

L'arbitrage institutionnel est organisé avec l'assistance d'une institution d'arbitrage préexistante, selon le règlement choisi par les parties. L'institution peut notamment intervenir dans l'administration de la procédure, la constitution du tribunal arbitral et la gestion des frais. Les parties conservent une liberté importante dans l'organisation de leur arbitrage, dans les limites du règlement applicable. L'institution ne se substitue pas aux arbitres pour trancher le litige : la sentence est rendue par le tribunal arbitral. Le caractère institutionnel ou ad hoc de l'arbitrage ne détermine pas, à lui seul, les conditions de reconnaissance ou d'exécution de la sentence par les juridictions étatiques

.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

Il existe de nombreux organismes. Certains sont généraux, et connaissent de tout type de contentieux international, tel que la CCI dont le siège est à Paris, ou la Cour d'arbitrage de Londres. D'autres sont spécialisés, tel que le CIRDI.

L'arbitrage ad hoc est organisé sans être administré par une institution d'arbitrage. Les parties disposent d'une grande liberté pour déterminer les règles de procédure, la désignation des arbitres et les modalités de déroulement de l'instance, sous réserve des règles impératives applicables. Cette souplesse peut toutefois entraîner des difficultés, notamment en cas de désaccord sur la constitution du tribunal arbitral. Les parties peuvent alors prévoir le recours à une autorité de nomination ou, lorsque les conditions sont réunies, à un juge d'appui. Pour faciliter l'organisation de l'arbitrage ad hoc, la CNUDCI propose un règlement d'arbitrage que les parties peuvent choisir d'appliquer. Ce règlement peut également être utilisé dans des arbitrages administrés par une institution.

.

9. La convention d'arbitrage

Il convient de distinguer entre la clause compromissoire et le compromis d'arbitrage. Ces deux types de conventions sont en effet distingués de manière très précise, en matière d'arbitrage interne, par l'article 1442 du code de procédure civile qui dispose que « la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage ». La distinction repose donc sur le moment auquel les parties conviennent de recourir à l'arbitrage : la clause compromissoire vise des litiges éventuels et futurs, tandis que le compromis porte sur un litige déjà né. .
L'article 2061 du Code civil prévoit que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle elle est opposée, sauf si celle-ci a succédé aux droits et obligations de la partie qui l'avait initialement acceptée. Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause compromissoire ne peut pas lui être opposée. Cette règle doit être distinguée du régime propre à l'arbitrage international, qui obéit notamment aux dispositions des articles 1504 et suivants du Code de procédure civile

Rareté du compromis. En pratique, le recours à la clause compromissoire est beaucoup plus fréquent que celui en faveur du compromis.

33. L'arbitrabilité du litige

Toutes les matières ne peuvent pas faire l'objet d'un arbitrage, de même que tout le monde ne peut pas consentir à l'arbitrage.

L'arbitrabilité subjective concerne l'aptitude des personnes à conclure une convention d'arbitrage. En droit interne, cette aptitude dépend notamment des règles relatives à la capacité et, le cas échéant, aux pouvoirs du représentant. Le mineur non émancipé ne peut pas librement conclure une convention d'arbitrage. La situation du mineur émancipé et celle du majeur protégé doivent être appréciées au regard des règles de capacité et de protection qui leur sont applicables. Il faut donc éviter de considérer que tous les majeurs protégés sont soumis à une interdiction identique de compromettre

.

En matière d'arbitrage international, l'arbitrabilité subjective soulève principalement deux difficultés : la capacité des personnes publiques à compromettre et la question du pouvoir du représentant de la société de recourir à l'arbitrage. L'article 2060 du Code civil pose en principe une interdiction de compromettre pour les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, sous réserve des exceptions prévues par les textes. Cette règle de droit interne ne doit toutefois pas être transposée mécaniquement à l'arbitrage international, dans lequel la capacité d'une personne publique à conclure une convention d'arbitrage appelle une analyse spécifique

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

L'arbitrabilité objective consiste à déterminer si la nature du litige permet qu'il soit tranché par des arbitres. Elle ne se confond pas avec la question de savoir si une règle impérative ou d'ordre public doit être appliquée au fond du litige. En droit interne, l'article 2059 du Code civil dispose que « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition ». L'article 2060 du Code civil exclut notamment l'arbitrage pour les questions d'état et de capacité des personnes, celles relatives au divorce et à la séparation de corps, ainsi que les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, sous réserve des exceptions prévues par les textes. Il vise également, plus généralement, les matières qui intéressent l'ordre public. Toutefois, la présence d'une règle d'ordre public dans un litige patrimonial ne suffit pas, à elle seule, à rendre ce litige inarbitrable : l'arbitre peut être amené à appliquer des règles impératives, sous le contrôle ultérieur du juge étatique dans les conditions prévues par le droit de l'arbitrage

.

34. Le choix des arbitres

En principe, les parties disposent d'une grande liberté pour organiser la composition du tribunal arbitral et les modalités de désignation des arbitres. Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 a assoupli le régime de la convention d'arbitrage. Il n'est plus nécessaire, à peine de nullité, que la clause compromissoire désigne les arbitres ou prévoie les modalités de leur désignation. En arbitrage interne, le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair (article 1451 du Code de procédure civile). La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits (article 1450 du même code)

.

Dans l'arbitrage ad hoc, les parties disposent d'une large liberté pour organiser la désignation des arbitres. Elles peuvent prévoir ces modalités à l'avance dans la clause compromissoire ou les convenir après la naissance du litige. Lorsque le tribunal arbitral comprend trois arbitres, il est fréquent que chaque partie en désigne un et que les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième, qui préside le tribunal arbitral. En cas de difficulté, l'intervention d'un juge d'appui peut être nécessaire. Dans l'arbitrage institutionnel, les parties s'appuient sur un règlement d'arbitrage qui fixera les modalités de désignation de l'arbitre.

.

.

35. Le principe de « compétence-compétence »

Le principe de compétence-compétence détermine la répartition des rôles entre l'arbitre et le juge étatique lorsqu'est contestée l'existence, la validité ou l'applicabilité d'une convention d'arbitrage. Son effet positif signifie que le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. En droit français, ce principe est consacré par l'article 1465 du Code de procédure civile

.

Son effet négatif signifie que le juge étatique saisi d'un litige relevant d'une convention d'arbitrage doit, en principe, laisser au tribunal arbitral le soin de se prononcer prioritairement sur sa compétence. Il ne s'agit toutefois pas d'une interdiction absolue pour le juge étatique d'examiner la convention d'arbitrage : l'article 1448 du Code de procédure civile prévoit un contrôle limité lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi. .

Ce principe posé à l'article 1448 al. 1er CPC n'est toutefois pas absolu : « *Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable* ». Par ailleurs, l'alinéa 2 précise que le juge étatique ne peut relever d'office son incompétence.

Il faut donc distinguer deux hypothèses :

- Si le tribunal arbitral est déjà saisi, le juge étatique devant lequel l'exception d'incompétence est invoquée doit, en principe, se déclarer incompétent au profit de l'arbitrage. Il ne peut pas appliquer l'exception tirée du caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la convention, laquelle suppose que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi.. .

 Tous droits réservés – Reproduction interdite

- Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, le juge étatique peut retenir sa compétence lorsque la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Le contrôle est limité au caractère manifeste du défaut invoqué : le juge ne doit pas procéder, à ce stade, à un examen approfondi de la compétence arbitrale. .

Dans les deux cas, le juge étatique ne peut pas relever d'office son incompétence sur le fondement de l'article 1448 du Code de procédure civile

36. La sentence arbitrale

La Cour de cassation définit la sentence comme « *les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur a été soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance* ».(Civile 1è 12 octobre 2011 n° 09-72.439) À titre d'exemple, une décision ordonnant simplement une mesure d'expertise ou organisant le déroulement de la procédure ne constitue pas, en principe, une sentence arbitrale : elle ne tranche pas définitivement tout ou partie du litige. Sa qualification ne dépend pas du seul intitulé que lui donnent les arbitres. La distinction est importante, car une véritable sentence peut, dans les conditions prévues par les textes, faire l'objet d'un recours en annulation et d'une demande de reconnaissance ou d'exequatur. Une simple mesure d'administration de la procédure ne relève pas de ces mécanismes en tant que sentence arbitrale.

.

 Tous droits réservés – Reproduction interdite